문제 1. 노동계약 규제 입법의 필요성

법학입문 · 압축 답안

문제 사적자치와 계약자유의 원칙에도 불구하고, 계약공정의 관점에서 사인 간 노동(근로)계약을 규제하기 위한 입법이 필요한 이유를 구체적인 예를 들어 설명하시오.

서론

근대 사법은 **사적자치**(자기결정·자기책임)를 원리로 하며, 여기서 **계약자유**가 나온다. 이에 따르면 노동계약도 노무와 보수를 교환하는 민법상 고용계약(제655조)이므로 근로조건은 당사자 합의에 맡겨야 한다. 그런데도 국가가 근로기준법 등으로 합의 내용까지 통제하는 이유는 노동계약에서 **계약자유의 전제인 힘의 균형**이 무너지기 때문이다.

본론

1. **계약자유의 전제와 계약공정의 원리**: 합의가 정당한 것은 당사자가 원했다는 **주관적 정당성** 때문이며, 이는 당사자가 내용을 이해하고 불리한 계약을 **거절할 수 있는 힘의 균형**을 전제로 한다. 이 전제가 무너지면 계약자유는 강자의 지배 수단이 되므로, 국가가 **객관적 정당성**의 관점에서 계약 내용을 통제해야 한다.

2. **노동계약에서 전제가 무너지는 이유**: ① 노동력은 사람의 몸·인격과 분리할 수 없는 **'허구 상품'**이다(폴라니). ② 생산수단이 없는 노동자는 노동력을 팔지 않으면 생존할 수 없어 **거절할 자유가 없다**(경제적 종속). ③ 계약 후에도 사용자의 **지휘·명령 아래 종속**이 계속된다. ④ 민법 고용 규정은 임의규정이고 제660조는 해고를 자유롭게 하며, 제104조(불공정 법률행위)는 요건이 엄격하고 계약 **전부를 무효**로 만들어 노동자 보호에 맞지 않는다.

3. **입법의 근거와 방식**: 헌법 제32조 제3항은 근로조건의 기준을 **인간의 존엄성**에 맞게 법률로 정하도록 한다. 근로기준법은 **최저기준**(제3조)에 못 미치는 부분만 무효로 하고 **법정 기준으로 채운다**(제15조).

4. **구체적 예**: ① 노동자가 동의한 최저임금 미달 약정도 미달 부분은 무효이고 최저임금액이 적용된다(최저임금법 제6조 제3항). ② 수당을 위해 동의한 장시간 노동도 건강·생명을 해치므로 **주 52시간제**로 제한된다. ③ "언제든 해고할 수 있다"는 조항은 **정당한 이유 없는 해고 금지**(근로기준법 제23조)에 반하며, 노동위원회·법원이라는 공적 제3자가 구제한다. ④ **5인 미만 사업장 적용 제외**, **중대재해처벌법** 등도 같은 원리에서 다룰 입법 쟁점이다.

결론

노동계약 규제는 계약자유를 **부정하는 것이 아니라 회복**하는 것이다. 국가는 **최저기준**을 정하고 그 위는 노동3권에 기초한 **집단적 자치**에 맡겨 실질적 자기결정을 보장한다. "노동은 상품이 아니다"라는 원칙처럼, 계약공정은 결국 **인간 존엄**의 문제다.

문제 2. 양심적 병역거부: 구·신 결정 비교

법학입문 · 압축 답안

문제 구 병역법 제5조 제1항이 양심적 병역거부자를 위한 대체역 복무를 정하지 않은 것이 헌법 제19조 양심의 자유 침해인지에 대한 (과잉금지원칙 심사에 따른) 헌법재판소의 구 결정과 신 결정을 비교하시오.

서론

구 병역법 제5조 제1항(병역종류조항)의 병역은 모두 **군사훈련을 전제**로 하여 대체역이 없었고, 거부자는 제88조 제1항(처벌조항)으로 처벌되었다. 쟁점은 이것이 **양심의 자유**, 특히 양심에 반하는 행동을 강요받지 않을 **부작위에 의한 양심실현의 자유**를 침해하는지이며, 기준은 **헌법 제37조 제2항의 과잉금지원칙**이다(문제의 "제1항"은 제2항이 정확함).

본론

1. **구 결정**(헌재 2004. 8. 26. 2002헌가1, 2011. 8. 30. 2008헌가22 등) — **합헌**: 처벌조항을 심사하며 양심의 자유를 국가에 양심을 '고려'해 달라는 권리로 좁게 보고, 국가안보 분야의 **넓은 입법재량**을 이유로 완화된 심사를 했다. 목적·수단은 정당하고, 대체복무는 남북 대치, 병력 손실, 양심 판정의 어려움, 형평성 문제 때문에 같은 효과를 보장하지 못하므로 **최소성 충족**, 국가안보가 중대하므로 **균형성 충족**이라고 보았다. 다만 2004년 결정은 대체복무 검토를 **권고**했다.
2. **신 결정**(헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등) — **병역종류조항 헌법불합치**: 대체역이 없는 병역종류조항을 직접 심사했다. 목적·수단은 인정했으나, 거부자는 연 수백 명이고 어차피 수감되어 병력이 되지 않으며, 엄격한 심사와 현역보다 무거운 복무로 위장과 형평 문제를 해결할 수 있으므로 **최소성 위반**, 공익은 대체복무로도 달성되는 반면 형사처벌·전과 등 불이익이 심대하므로 **균형성 위반**이라고 보았다(6:3, 2019. 12. 31.까지 개선입법). 처벌조항은 합헌(4:4:1)으로 남았다.

구분	구 결정	신 결정
심판대상	처벌조항	병역종류조항
심사 강도	입법재량 존중(완화)	엄격한 과잉금지 심사
최소성·균형성	충족	위반
형량 방식	양자택일(양심 vs 안보)	조화(대체복무로 공존)
결론	합헌 + 입법 권고	헌법불합치 + 입법 명령

결론

신 결정은 위헌성의 원인을 '처벌'이 아니라 **'대안 없는 입법'**에서 찾고, 양심과 안보를 **대체복무로 조화**시키도록 입법자에게 의무를 지웠다. 이후 대법원 전원합의체(2018. 11. 1. 2016도10912)가 양심적 병역거부를 '정당한 사유'로 보아 무죄로 판단했고, **대체역법(2019)**으로 36개월 대체복무가 도입되었다. 소수자의 양심을 보호한 진전이지만, 대체복무가 징벌적이지 않도록 **실질적 등가성**을 갖추는 과제가 남아 있다.

문제 3. 공법관계와 사법관계

문제 공법관계와 사법관계의 의의와 양자의 차이점을 설명하시오.

서론

근대 법질서는 **국가와 사회(시장)를 구분**하고, 이에 따라 법도 사적자치를 원리로 하는 **사법**과 공익 실현을 원리로 하는 **공법**으로 나뉜다. 어떤 법률관계가 어디에 속하느냐에 따라 **적용 법규와 구제 절차**가 달라지므로 구별이 중요하다.

본론

1. **의의**: **사법관계**는 대등한 사인 간의 법률관계로, 사적자치가 적용되고 의사의 합치(계약)로 형성된다. 국가가 사인과 같은 지위에서 물품을 사는 **국고관계**도 사법관계다. **공법관계**는 행정주체가 공권력·공익 실현의 주체로서 사인과 맺는 관계로, 법률에 근거해 **일방적으로** 형성된다(권력관계·관리관계).
2. **구별 기준**: 이익설·종속설·신주체설이 있으나, 관계 법규의 목적과 성질을 **종합**하여 판단한다. 예컨대 같은 토지 취득도 협의취득은 사법상 매매, 수용재결은 공법상 처분이다.
3. **차이점**:

구분	사법관계	공법관계
원리	사적자치	법률적합성, 행정법 일반원칙(비례·신뢰보호 등)
형성	계약, 방식 자유	처분, 행정절차법
효력	하자 시 무효·취소	공정력·불가쟁력
강제	자력강제 불가(판결·민사집행)	행정상 강제집행(대집행·강제징수 등)
손해전보	민법 제750조	국가배상법, 손실보상(헌법 제23조 제3항)
쟁송	민사소송법	행정소송법(항고·당사자소송)
이익 조정	대등한 사익 조정(신의칙·권리남용 금지)	공익과 사익 형량(과잉금지·본질적 내용 침해 금지)

결론

오늘날 노동법·경제법 같은 **사법의 공법화**와 공법상 계약·행정사법 같은 **공법의 사법화**로 경계가 상대화되었다. 그러나 적용 법규·강제 수단·구제 절차가 여전히 다르므로 **구별의 실익**은 남아 있다. 공·사법의 구별은 사적 자율을 존중하면서 **공권력을 법으로 통제**하려는 법질서의 기본 설계다.